

- **Procedimiento N°: EXP202401528 (PS/00197/2024)**

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 28/12/23, **D. A.A.A.** (la parte reclamante), presenta escrito de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La reclamación se dirige contra la entidad ALL IN DIGITAL MARKETING SL, con NIF.: B88369178, (la parte reclamada), por la presunta vulneración de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI).

Los hechos que manifiesta el reclamante en su escrito son que ante la multitud de correos electrónicos de publicidad recibidos desde allzoners@allzone.es, solicitó tanto en respuesta a esa misma dirección como a la que aparece en su política de privacidad de su web, delegadodatos@allindigital.es, la baja de los sistemas de la empresa para seguir recibiendo publicidad, pero pese a ello, sigue recibéndolos.

Junto al escrito de reclamación, se acompaña la siguiente documentación:

- Fechado el 14/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante *****EMAIL.1** a la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, conteniendo el siguiente mensaje:
 - o *"Buenas tardes, he cancelado la inscripción para recibir sus correos electrónicos a través del enlace que aparece en la parte inferior de sus correos unas 10 veces y continúo recibéndolos, por lo que solicito que me den de baja inmediatamente de su lista de distribución o procederé a tomar medidas".*
- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamado allzoners@allzone.es, a la dirección de correo electrónico, *****EMAIL.1**, con asunto: *"ÚLTIMOS DIAS. Participa ahora y llévate GRATIS este pack o viaje a París"* y el siguiente mensaje:
 - o *"SORTEAZO PACK APPLE. - Vótanos..."*
- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante *****EMAIL.1** a la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, conteniendo el siguiente mensaje:
 - o *"Veo que sigo recibiendo correos electrónicos sin que se haya producido la baja. Esperaré el tiempo que marca la Ley para que se aplique, si pasado ese tiempo sigo recibiendo correos electrónicos por su parte, procederé a interponer la correspondiente denuncia ante la AEPD".*

- Pantallazo de la página de la “Política de Privacidad” de la web <https://allzone.es>, (<https://allzone.es/content/2-politica-de-privacidad>) donde se puede leer, entre otras cuestiones, lo siguiente:
 - o (...) Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de ALL IN DIGITAL MARKETING SL o al correo electrónico habilitado a tal efecto, delegadodatos@allindigital.es, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI por ambas caras o la autorización firmada de su representante legal (...).
- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante ***EMAIL.1 a la dirección de correo electrónico, delegadodatos@allindigital.es conteniendo el siguiente mensaje:
 - o “Mediante el presente correo adjunto documentación para que procedan a darme de baja de la lista de distribución de correos electrónicos publicitarios ya que mediante el enlace de la parte inferior de los correos que recibo y respondiendo a esa misma dirección solicitando la baja no ha resultado efectivo”.
- Fechados el 21/09/23, el 05/10/23, el 12/10/23, el 02/11/23, el 09/11/23, el 14/11/23, el 24/11/23, el 25/11/23, el 14/12/23, 19/12/23 y 23/12/23 copia de los correos electrónicos enviados desde la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, a la dirección de correo ***EMAIL.1 conteniendo mensajes publicitarios, como el siguiente:
 - o *SORTEAZO. Tus nuevos compañero Apple. Valoramos tu premio. ¡Últimas horas! Queremos agradecerte tu confianza, para ello no se nos ocurre mejor regalo que ofrecerte la posibilidad de ganar este increíble regalo. Llévate ahora COMPLETAMENTE GRATIS este combo de APPLE (...).*

SEGUNDO: Con fecha 31/01/24, de conformidad con lo estipulado en el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, (LOPDGDD), por parte de esta Agencia, se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada para que procediese a su análisis e informase, en el plazo de un mes, sobre lo que se exponía en el escrito de reclamación.

El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) mediante notificación electrónica, fue recogido por el responsable, dentro del plazo de puesta a disposición, el 02/02/24.

TERCERO: Con fecha 01/03/24, se recibe en esta Agencia escrito de contestación de la entidad reclamada, en el cual, manifiesta lo siguiente:

- Que el cliente se registró en la plataforma “allzone.es” el 13/07/20 para la realización de una compra on-line, y posteriormente el 18/04/22 para una segunda compra, aceptando todas las condiciones generales, la política de privacidad, la suscripción a boletines de noticias y las ofertas asociadas de forma voluntaria. La aceptación de estas condiciones fue totalmente explícita.
- Que los clientes tienen la posibilidad de gestionar libremente su suscripción al boletín de noticias y las ofertas asociadas desde el apartado “Información Personal” de su área de cliente y en cualquier momento pueden darse de baja o volver a suscribirse según lo consideren oportuno.
- Que cada vez que un cliente solicita la baja de los servicios mencionados, el sistema procesa la baja de forma automática recibiendo un correo electrónico de confirmación enviado desde el servidor de la empresa. Sin embargo, si el cliente accede nuevamente a su cuenta y vuelve a aceptar las condiciones de uso, su suscripción se reactivará de forma automática y comienza de nuevo a recibir comunicaciones comerciales.
- Que la razón por la cual el cliente ha recibido comunicaciones comerciales después de haber solicitado la baja es que volvió a acceder a la plataforma y a aceptar las condiciones.

TERCERO: Con fecha 28/03/24, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.

CUARTO: Con fecha 05/06/24, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la entidad ALL IN DIGITAL MARKETING SL, con CIF.: B88369178 con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la LPACAP, por la presunta infracción del artículo 21 de la LSSI, tipificada como leve en el art. 38.4.d) de la misma norma.

En el acuerdo de apertura se determinó que la sanción que pudiera corresponder, atendidas las evidencias existentes en el momento de la apertura y sin perjuicio de lo que resultase de la instrucción, ascendería a un total de 20.000 euros (veinte mil euros).

QUINTO: Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la LPACAP, la reclamada presentó alegaciones el día 26/06/24, en las que, además de ratificar las mismas alegaciones de su escrito de fecha 01/03/24, manifiesta:

- Que dada que la relación comercial se desarrolla de forma online, la única prueba que puede aportar es el registro de la “Ficha del Cliente”, que muestra los envíos de los correos electrónicos automáticos para confirmar las altas y bajas en sus suscripciones.
- Que en cuanto a la imputación de reincidencia basada en el expediente PS/00574/2023, subraya que dicho expediente fue recibido el 17/01/24 y que presentó alegaciones y propuestas de actuación el 07/02/24 y que por lo tanto, los hechos que se consideran reincidentes son anteriores a estas actuaciones preventivas.

Junto al escrito de alegaciones, la reclamada presenta la siguiente documentación:

- Pantallazo del formulario “vacío” de registro como cliente en la página web www.allzone.es (inicio→ su cuenta) donde se puede comprobar como las opciones “_ suscribirse al boletín de noticias” y “_ he leído y acepto la Política de Privacidad” se encuentran inicialmente desmarcadas.
- Pantallazo de la “Ficha Cliente” del reclamante donde se puede leer, entre otra información, la siguiente:

Estado:	Últimos e-mails enviados:
13/07/2020 Alta	02/02/2024 09:32:45
14/09/2023 Baja	20/09/2023 19:04:37
17/09/2023 Alta	19/09/2023 08:51:23
19/09/2023 Baja	17/09/2023 23:30:44
20/09/2023 Alta	14/09/2023 06:18:55...
02/02/2024 Baja	

- Fechado el 13/07/20 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 13/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 17/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 19/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 20/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 02/02/24 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.*

SEXTO: Con fecha 03/10/24 se formuló propuesta de resolución en el sentido de que por la Directora de la AEPD sancionase a la entidad ALL IN DIGITAL MARKETING SL, con una sanción de 5.000 euros (cinco mil euros), por la infracción del artículo 21 de la LSSI, tipificada como leve en el art. 38.4.d), al determinarse que la incoación del presente procedimiento sancionador (el PS/00197/2024) se realizó antes de que el procedimiento sancionador anterior (el PS/00574/2023) fuera firme en vía administrativa por lo que, para el presente procedimiento sancionador, no cabría considerar como agravante el apartado c) del artículo 40 de la LSSI.

SÉPTIMO: Con fecha 15/10/24, la parte reclamada presenta escrito de alegaciones a la propuesta de resolución reiterando las ya presentadas a la incoación del expediente. En concreto manifiesta lo siguiente:

1º Que el cliente se registró en la web allzone.es el día 13/07/2020, para la realización de su pedido referencia 5519 y el día 18/04/2022 el siguiente pedido con referencia 58816, aceptando todas las condiciones generales de compra, política de privacidad, suscripción a boletín de noticias y ofertas de asociados. (Adjuntamos-DOC1 documento donde se ve un ejemplo del momento del registro en el que el cliente acepta la política de privacidad y da su consentimiento a comunicaciones sobre nuestro boletín y ofertas asociadas) Cabe destacar que el acceso al área de clientes solo lo puede realizar este accediendo con sus credenciales personales y privados por lo que el documento que mostramos es a modo ejemplo genérico.

3º Que el usuario tiene la posibilidad de acceder a su área de clientes y darse de baja y alta en las comunicaciones comerciales, suscripción a boletín y ofertas asociadas tantas veces como desee o estime oportunas, a través del apartado datos personales, dando clic al check box, y a continuación a la tecla guardar (Adjuntamos documento ejemplo DOC2). Tal y como se ha indicado en el punto 2 de nuestras alegaciones solo el cliente puede acceder con sus credenciales a su área personal, por lo que el DOC2 es un ejemplo genérico.

Cada vez que el usuario realiza este proceso es informado mediante correo electrónico de su situación de alta o baja en la suscripción. Al tratarse de una web online, la única justificación que podemos aportar es el registro de la ficha de cliente donde se ve cuando nuestro servidor dispara dichos emails hacia el usuario con la comunicación. (Adjuntamos ficha completa del cliente DOC3) Subrayando las fechas en las que nos consta cada alta y baja en el servicio de comunicaciones comerciales y además Adjuntamos la cronología de correos enviados al cliente para comunicar el alta y baja a news letter (DOC4) Documento conjunto donde se puede ver el memorando de cada email emitido cuya dirección destinataria es la registrada por el cliente en su ficha, véase DOC3). Estas pruebas se consideran fehacientes, y no hacer uso de ellas como fundamento de alegato sería una violación a los derechos legales que la parte demandada tiene para impugnar la propuesta de sanción recibida. Cabe resaltar que interpretar de forma errónea o manipular la interpretación de un documento fehaciente para justificar una sanción, podría constituir un exceso de competencias por parte del funcionario, al actuar con ánimo recaudatorio en detrimento de los derechos del recurrente.

4º Que ante la respuesta de este organismo sobre la tipificación de la infracción podemos ALEGAR:

1. Que en ningún caso ha habido intencionalidad por parte de la reclamada ALL IN DIGITAL MARKETING SL, ya que como se ha explicado en los puntos 1,2 y 3 de las alegaciones, es el cliente de forma voluntaria el que puede acceder a sus datos y otorgar la autorización o retirarla para que esta use sus datos para fines de comunicación comercial. Como comercio no podemos prohibir a un cliente que deje de estar interesado o vuelva a estarlo en nuestras ofertas o comunicaciones cuando crea oportuno.

2. Que como hecho reincidente sobre actos de la misma naturaleza ponen como ejemplo el expediente PS/00574/2023, cabe destacar que este expediente fue recibido por la reclamada el día 17/01/2024, siendo presentadas sus alegaciones y propuestas de actuación para la prevención de este tipo de situaciones el día 07/02/2024, tal y como se indica en el expediente al que hacemos alusión en este escrito, el cliente, reclamó a este organismo el día 28/12/2023 , por lo que queda claro que los hechos son anteriores a nuestras ALEGACIONES Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN sobre el expediente que consideran como ejemplo de reincidencia.

5º Cabe destacar que hemos analizado los tres casos que actualmente tenemos con la AEPD, y observamos que el modus operandi de los denunciantes siempre es el mismo, manipulan el alta y baja de aceptación de comunicaciones comerciales y News letter desde su área de clientes y luego seguidamente denuncian haber recibido comunicaciones comerciales sin su consentimiento para impugnarnos.

Además, los denunciantes alardean de esto publicando en redes sociales las denuncias puestas a la Agencia española de protección de datos, lo que nos certifica aún más que son personas que quieren darse a conocer e incitar a otras personas a que también atenten contra la empresa denunciada.

En todos los casos la AEPD acepta y da credibilidad a las declaraciones de los denunciantes ignorando todos nuestros recursos alegatorios, que además se acompañan con pruebas fehacientes de los hechos alegados, para continuar con las propuestas de sanción interpuestas, lo que nos hace plantearnos si se trata de un mecanismo de acción contra nuestra empresa para presuntamente difamarnos y perjudicarnos

La AEPD está actuando, ignorando las alegaciones y pruebas presentadas y en sí los hechos atentando esto contra nuestra legítima defensa, con un espíritu claramente recaudatorio.

De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y de la documentación obrante en el expediente, han quedado acreditados los siguientes

HECHOS PROBADOS

Primero: Queda constancia en el expediente de la siguiente documentación aportada por el reclamante:

- Fechado el 14/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante *****EMAIL.1** a la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, conteniendo el siguiente mensaje:
 - o *“Buenas tardes, he cancelado la inscripción para recibir sus correos electrónicos a través del enlace que aparece en la parte inferior de sus correos unas 10 veces y continúo recibiendo, por lo que solicito que me den de baja inmediatamente de su lista de distribución o procederé a tomar medidas”.*
- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamado allzoners@allzone.es, a la dirección de correo electrónico, *****EMAIL.1**, con asunto: “ÚLTIMOS DIAS. Participa ahora y llévate GRATIS este pack o viaje a París” y el siguiente mensaje:
 - o *“SORTEAZO PACK APPLE.- Vótanos...”*
- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante *****EMAIL.1** a la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, conteniendo el siguiente mensaje:
 - o *“Veo que sigo recibiendo correos electrónicos sin que se haya producido la baja. Esperaré el tiempo que marca la Ley para que se aplique, si pasado ese tiempo sigo recibiendo correos electrónicos por su parte, procederé a interponer la correspondiente denuncia ante la AEPD”.*
- Pantallazo de la página de la “Política de Privacidad” de la web <https://allzone.es>, (<https://allzone.es/content/2-politica-de-privacidad>) donde se puede leer, entre otras cuestiones, lo siguiente:
 - o *(...) Los titulares de los datos personales obtenidos, podrán ejercer sus derechos de protección de datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al domicilio social de ALL IN DIGITAL MARKETING SL o al correo electrónico habilitado a tal efecto, delegadodatos@allindigital.es, incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI por ambas caras o la autorización firmada de su representante legal (...).”*
- Fechado el 19/09/23, copia del correo electrónico enviado desde la dirección del reclamante *****EMAIL.1** a la dirección de correo electrónico, delegadodatos@allindigital.es conteniendo el siguiente mensaje:

- o *“Mediante el presente correo adjunto documentación para que procedan a darme de baja de la lista de distribución de correos electrónicos publicitarios ya que mediante el enlace de la parte inferior de los correos que recibo y respondiendo a esa misma dirección solicitando la baja no ha resultado efectivo”.*
- Fechados el 21/09/23, el 05/10/23, el 12/10/23, el 02/11/23, el 09/11/23, el 14/11/23, el 24/11/23, el 25/11/23, el 14/12/23, 19/12/23 y 23/12/23 copia de los correos electrónicos enviados desde la dirección de correo electrónico, allzoners@allzone.es, a la dirección de correo *****EMAIL.1** conteniendo mensajes publicitarios, como el siguiente:
 - o *SORTEAZO. Tus nuevos compañero Apple. Valoramos tiene premio. ¡Últimas horas! Queremos agradecerte tu confianza, para ello no se nos ocurre mejor regalo que ofrecerte la posibilidad de ganar este increíble regalo. Llévate ahora COMPLETAMENTE GRATIS este combo de APPLE (...).”.*

Segundo: Queda constancia en el expediente de la siguiente documentación aportada por la reclamada:

- Pantallazo del formulario “vacío” de registro como cliente en la página web www.allzone.es (inicio→ su cuenta) donde se puede comprobar como las opciones “suscribirse al boletín de noticias” y “he leído y acepto la Política de Privacidad” se encuentran inicialmente desmarcadas.
- Pantallazo de la “Ficha Cliente” del reclamante donde se puede leer, entre otra información, la siguiente:

Estado:	Últimos e-mails enviados:
13/07/2020 Alta	02/02/2024 09:32:45
14/09/2023 Baja	20/09/2023 19:04:37
17/09/2023 Alta	19/09/2023 08:51:23
19/09/2023 Baja	17/09/2023 23:30:44
20/09/2023 Alta	14/09/2023 06:18:55...
02/02/2024 Baja	

- Fechado el 13/07/20 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 13/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.*

- Fechado el 17/09/20 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 19/09/23 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 20/09/20 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., GRACIAS POR SUSCRIBIRSE A NUESTRA NEWSLETTER.*
- Fechado el 02/02/24 copia del correo electrónico enviado desde la dirección AllZone no-reply-info@allzone.es a la dirección *****EMAIL.1** con el siguiente mensaje: *HOLA A.A.A., SE HA DADO DE BAJA CORRECTAMENTE DE NUESTRA NEWSLETTER.*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1 de la LSSI y lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la LOPDGDD, es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: "Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos."

La Disposición adicional cuarta "Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes" establece que: *"Lo dispuesto en el Título VIII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes."*

II

Contestación a las alegaciones presentadas:

Primero: Como cuestión previa, procede recordar que en el escrito de reclamación presentado por el reclamante, éste manifestaba que, tras haber recibido una multitud de correos electrónicos de naturaleza publicitaria enviados por la entidad reclamada, solicitó, tanto mediante respuesta a dichos correos como a través de la dirección facilitada en la política de privacidad disponible en su página web, su baja de los

sistemas de distribución de correos publicitarios. Sin embargo, a pesar de dicha solicitud, continuó recibiendo tales comunicaciones.

A la reclamación se adjuntaron copias de los correos electrónicos remitidos por el reclamante solicitando su baja de la lista de distribución, así como de los correos publicitarios recibidos con posterioridad a dicha solicitud.

Por su parte, la entidad reclamada, a lo largo de todo el procedimiento, ha sostenido en sus escritos de respuesta a la solicitud de información emitida por esta Agencia, en las alegaciones presentadas tras la incoación del expediente y en sus últimas alegaciones a la propuesta de resolución, que, siempre que un cliente solicita la baja del servicio de comunicaciones comerciales, dicha baja se ejecuta automáticamente en su sistema, siendo informado el cliente mediante un correo electrónico de confirmación automática. No obstante, la entidad ha señalado que si el cliente vuelve a acceder a su cuenta en la web con sus credenciales y acepta nuevamente las condiciones de uso, los servicios se reactivan automáticamente, lo que incluye la recepción de comunicaciones comerciales.

En relación con el punto "Primero" de las alegaciones de la entidad reclamada, ésta manifiesta que el reclamante se registró en la web www.allzone.es el día 13/07/20 para realizar una compra online, aceptando las condiciones generales de contratación, la política de privacidad, la suscripción a boletines informativos y ofertas de asociados.

De la documentación aportada por el reclamante junto a su escrito de reclamación, destacan los correos electrónicos enviados los días 14/09/23 y 19/09/23 a la dirección allzoners@allzone.es, en los que el reclamante manifiesta su deseo de no recibir más correos publicitarios, advirtiendo de la posibilidad de adoptar medidas en caso de persistir el envío de dichas comunicaciones. Además, el mismo día 19/09/23, el reclamante también remitió otro correo electrónico al Delegado de Protección de Datos de la entidad, delegadodatos@allindigital.es, solicitando nuevamente la baja de la lista de distribución de correos publicitarios.

De la documentación aportada por la entidad reclamada, en concreto del documento denominado "Ficha Cliente", se desprende que el reclamante figura como dado de "baja" el día 19/09/23 y en estado de "alta" en el sistema el día 20/09/23, tras lo cual recibió hasta 11 correos publicitarios en fechas posteriores.

Pues bien, la entidad reclamada alega que la suscripción se reactiva automáticamente cuando el cliente accede nuevamente a su cuenta aceptando las condiciones de uso, y esto parece ser que ocurrió el 20/09/23, según consta en la "Ficha Cliente" y en el correo automático enviado por la reclamada ese mismo día, pero no aporta prueba alguna que lo acredite, o que acredite que el reclamante otorgó su consentimiento expreso para recibir publicidad comercial. Esto es, no se aporta el registro (log) de las actuaciones realizadas por el reclamante cuando, según la reclamada, volvió a acceder el día 20/09/23, que pueda demostrar que volvió a dar el consentimiento expreso para volver a recibir comunicaciones comerciales, después de haber solicitado hasta en tres ocasiones la eliminación de sus datos de los sistemas de la entidad para no seguir recibéndolos.

Segundo: En el apartado marcado como "tercero" del escrito de alegaciones, la entidad reclamada argumenta que cualquier usuario tiene la facultad de gestionar sus suscripciones a comunicaciones comerciales y boletines a través de su área personal en la página web. Según lo expuesto, el usuario puede darse de alta o baja en cualquier momento mediante un proceso que consiste en marcar una casilla de verificación ("check box") y guardar los cambios, tras lo cual recibe una notificación electrónica confirmando su estado. La empresa aporta como prueba la ficha del cliente, donde constan las fechas de alta y baja, así como un cronograma de los correos electrónicos enviados al usuario.

Por su parte, tras el análisis de los correos electrónicos publicitarios recibidos por el reclamante, se ha verificado que al final de cada uno de dichos correos aparece la siguiente información: *"Recibes este correo porque te has suscrito a la lista de All Zone o porque has proporcionado tu dirección de correo en algún evento realizado, y creemos que la información proporcionada puede ser de tu interés. <<[Cancelar suscripción](#)>>"*.

En relación con los hechos, el reclamante sostiene que solicitó la baja del servicio a través de dicho enlace en, aproximadamente, diez ocasiones, aportando como prueba las respuestas automáticas recibidas que lo confirman: *"se ha dado de baja correctamente"*.

En consecuencia, resulta evidente que el reclamante, al hacer uso de la opción proporcionada por la reclamada en los correos electrónicos publicitarios, solicitó correctamente la baja del servicio y recibió confirmación automática de dicha baja. Sin embargo, el reclamante siguió recibiendo correos electrónicos publicitarios, lo que motivó el envío de dos correos electrónicos adicionales a la dirección allzoners@allzone.es los días 14/09/23 y 19/09/23, así como otro correo al Delegado de Protección de Datos de la entidad (DPD), dirigido a delegadodatos@allindigital.es el 19/09/23, en los que solicitaba nuevamente que cesara el envío de correos publicitarios.

Pese a ello, tal como ha quedado debidamente constatado, dicha solicitud no produjo efecto alguno, dado que el reclamante continuó recibiendo hasta un total de once nuevos correos electrónicos publicitarios en los tres meses posteriores (desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2023).

En el escrito remitido por la reclamada a esta Agencia con fecha 01/03/24, afirma que *"...si el cliente accede nuevamente a la web con sus credenciales y acepta las condiciones generales, incluyendo la activación de los servicios, volvería a suscribirse automáticamente, lo que derivaría en la recepción de nuevas comunicaciones comerciales"*.

De lo anterior, se desprende que, si bien el cliente puede gestionar la baja de las comunicaciones comerciales, el simple hecho de acceder nuevamente a la web con sus credenciales para realizar un nuevo pedido, por ejemplo, implicaría la reactivación automática de la suscripción a las "newsletter", incluso si el cliente había manifestado previamente su deseo de no volver a recibir más comunicaciones comerciales.

Este hecho se corrobora con la documentación aportada por la reclamada, en la que se evidencia que únicamente en el primer formulario de registro se solicita el consentimiento explícito para la recepción de publicidad. La entidad no ha aportado pruebas que demuestren que, en accesos posteriores a la web, se haya requerido nuevamente el consentimiento específico para la recepción de comunicaciones comerciales. En este sentido, se debe dejar claro que no es suficiente el acceso a la web para considerar que el usuario ha otorgado nuevamente su consentimiento para el envío de publicidad, debiendo existir un consentimiento expreso y específico conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Tercero: En el punto marcado como “cuarto” de su escrito de alegaciones, la reclamada además de volver a reiterar que el cliente, de forma voluntaria, puede acceder a su área privada de la web y darse de baja/alta del servicio de comunicaciones comerciales, manifiesta su objeción a utilizar como agravante para calcular la sanción la “reincidencia” pues indica que el reclamante interpuso reclamación ante la AEPD el día 28/12/23 dando lugar al presente expediente y que respecto del PS/00574/2023, fue recibido por la reclamada el día 17/01/24, siendo presentadas sus alegaciones y propuestas de actuación para la prevención de este tipo de situaciones el día 07/02/24.

Pues bien, indicar que este punto ya se trató en la “Propuesta de “Resolución” donde se determinó que la incoación del presente procedimiento sancionador (el PS/00197/2024) se realizó antes de que el procedimiento sancionador anterior (el PS/00574/2023) fuera firme en vía administrativa por lo que, para el presente procedimiento sancionador, no cabe considerar como agravante el apartado c) del artículo 40 de la LSSI y por tanto se debía reconsiderar la sanción a imponer, proponiendo una sanción de 5.000 euros, acorde con la sanción impuesta en el anterior expediente, el PS/00574/2023.

Cuarto: En el punto “quinto” de su escrito de alegaciones, la reclamada manifiesta que, ha detectado un patrón común en las tres denuncias presentadas contra la empresa ante la AEPD, señalando que los denunciantes manipulan las altas y bajas de las comunicaciones comerciales desde su área de clientes, para posteriormente denunciar haber recibido dichas comunicaciones sin su consentimiento.

Respecto a estas alegaciones indicar que la AEPD no tiene competencia para investigar si los denunciantes han actuado de manera fraudulenta al manipular su consentimiento. En todo caso ese factor sería irrelevante para este expediente, en que se enjuicia la corrección de la actuación del reclamado en caso de recibir una solicitud de oposición a la recepción de comunicaciones comerciales.

No obstante, indicar que este tipo de acciones podrían constituir, en su caso, un fraude o un abuso de derecho, lo cual correspondería dirimir a otras autoridades competentes en vía judicial.

También sostiene reclamada en este apartado que, a pesar de aportar pruebas que acreditan sus alegaciones, la AEPD otorga credibilidad a los denunciantes y continúa con las propuestas de sanción, lo que lleva a la reclamada a cuestionar si se está utilizando este mecanismo para difamarla y perjudicarla. Finalmente, acusa a la AEPD

de actuar con un ánimo recaudatorio, ignorando las pruebas y atentando contra su derecho a la defensa.

Pues bien, en este sentido solamente indicar que las acusaciones que vierte la reclamada sobre parcialidad, ánimo recaudatorio y difamación de la AEPD carecen de sustento. La AEPD actúa conforme a la ley, garantiza el derecho de defensa y evalúa las pruebas aportadas de manera objetiva, con el único propósito de asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y los derechos de los usuarios.

III

Prohibición de comunicaciones comerciales no solicitadas o expresamente autorizadas

La LSSI prohíbe las comunicaciones comerciales no solicitadas o expresamente autorizadas, partiendo de un concepto de comunicación comercial que se califica como servicio de la sociedad de la información y que se define en su Anexo como: *“f) Comunicación comercial»: toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.*

Por tanto, el concepto de comunicación comercial, de acuerdo con la definición anterior, engloba todas las formas de comunicaciones destinadas a promocionar directa o indirectamente bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.

Por otro lado, la LSSI en su Anexo a) define “Servicio de la Sociedad de la Información” como *“todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario*

El concepto de “Servicio de la Sociedad de la Información” comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios”.

Según el apartado d) del citado Anexo, destinatario es la *“persona física o jurídica que utiliza, sea o no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información”*

IV

Tipificación de la infracción cometida por el envío de comunicaciones comerciales que no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas.

El artículo 21 de la LSSI, pues establece lo siguiente:

“1. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de estas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de

comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.”

En el presente caso, se constata que el reclamante ha intentado darse de baja en el sistema para no volver a recibir más correos electrónicos publicitarios de la entidad reclamada en varias ocasiones pero sigue recibiendo correos electrónicos publicitarios. Pese a ello, presentando para corroborarlo copia de los correos electrónicos enviados solicitando la baja y los correos electrónicos publicitarios recibidos.

Por su parte, la entidad reclamada manifiesta que siempre que el cliente solicita la baja de los servicios mencionados, ésta se hace automáticamente y se envía acuse al cliente de la nueva situación, pero si el cliente vuelve a acceder a la web, con sus credenciales y vuelve a aceptar las condiciones y activar los servicios, automáticamente vuelve a estar suscrito y puede empezar a recibir nuevamente comunicaciones comerciales, pero en ningún momento presenta prueba del mensaje que envía al cliente comunicándole que la baja del sistema se ha producido correctamente.

Tampoco presenta prueba de que el reclamante al acceder nuevamente a la zona de clientes de la web haya vuelto a dar su consentimiento para que se active nuevamente la recepción de correos electrónicos publicitarios, ni presenta prueba de la respuesta que el DPD pueda haber enviado al reclamante, cuando éste se puso en contacto con él a través de su correo electrónico.

En este sentido se debe dejar claro que, una vez ejercido el derecho de oposición, no resulta posible considerar que el usuario de la web, por el mero hecho de acceder nuevamente a ella a través de sus claves, esté otorgando un nuevo consentimiento. En este caso, la normativa exige un consentimiento expreso. Esto es, una declaración clara e inequívoca del interesado, de forma que permita la constancia y prueba indubitada de haber revocado su deseo de oposición.

Por tanto, el hecho de que el reclamado siga enviando correos electrónicos publicitarios al reclamante después de que éste haya manifestado su deseo de no volver a recibir más correos electrónicos de este tipo sin aportar ninguna prueba de que el reclamante haya vuelto a dar su consentimiento para volver a recibirlos constituye una vulneración de lo establecido en el artículo 21 de la LSSI.

V Sanción

La citada infracción se encuentra tipificada como “leve” en el art. 38.4.d) de dicha norma, que califica como tal, *“El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente cuando en dichos envíos no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 21 y no constituya infracción grave”*.

A tenor de lo establecido en el artículo 39.1.c) de la LSSI, las infracciones leves podrán sancionarse con multa de hasta 30.000 €.

El artículo 40 de la LSSI establece los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones: *La cuantía de las multas que se impongan se graduará atendiendo a los siguientes criterios: a) La existencia de intencionalidad. b) Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. c) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. d) La naturaleza y cuantía de los perjuicios causados. e) Los beneficios obtenidos por la infracción. f) Volumen de facturación a que afecte la infracción cometida. g) La adhesión a un código de conducta o a un sistema de autorregulación publicitaria aplicable respecto a la infracción cometida, que cumpla con lo dispuesto en el artículo 18 o en la disposición final octava y que haya sido informado favorablemente por el órgano u órganos competentes.*

Tras las evidencias obtenidas, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los siguientes criterios agravantes, que establece el art. 40 de la LSSI:

- La existencia de intencionalidad (apartado a), pues se constata que el reclamante ha intentado darse de baja en el listado de correos electrónicos publicitarios de la entidad reclamada en varias ocasiones, tanto a través del enlace existente en los correos recibidos como a través del Delegado de Protección de datos de la entidad, pero sigue recibiendo correos electrónicos publicitarios.

Con arreglo a dichos criterios, se estima adecuado imponer una sanción de 5.000 euros (cinco mil euros), por la infracción del artículo 21.1 de la LSSI.

RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER a la entidad, ALL IN DIGITAL MARKETING SL, con CIF.: B88369178, por infracción del artículo 21 de la LSSI, tipificada en el artículo 38.4.d) de la citada norma, una multa de **5.000 euros (cinco mil euros)**.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a ALL IN DIGITAL MARKETING SL,

TERCERO: Advertir al sancionado que deberá hacer efectiva la sanción impuesta una vez que la presente resolución sea ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en el plazo de pago voluntario establecido en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado

por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso, indicando el NIF del sancionado y el número de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento, en la cuenta restringida **Nº IBAN: ES00-0000-0000-0000-0000-0000 (BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX)**, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A..

En caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo. Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

